

1500746-37.2020.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: NAIRA BLANCO MACHADO

Comarca: Arujá

Foro: Foro de Arujá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... e venda da droga, nem anotações de tráfico, balanças, insumos ou quaisquer outros instrumentos que estão usualmente atrelados ao delito. Ademais, não foram apreendidos os celulares dos acusados, não ficando evidenciada qualquer comunicação entre eles que indicassem tráfico de drogas ou tratativas relativas ao tráfico. Convém anotar ainda, por oportuno, que a prova ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Arujá

Foro de Arujá

1ª Vara

Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Aruja - SP - cep 07400-000

1500746-37.2020.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500746-37.2020.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON DE OLIVEIRA MOTA e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). NAIRA BLANCO MACHADO

Vistos.

DELIVAN SANTANA SANTOS e ANDERSON DE OLIVEIRA MOTA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas penas do artigo 33, caput e artigo 35 da Lei nº 11.343/06, pois, em data anterior e até 01 de abril de 2020, associaram-se entre eles, para o fim de praticar, de forma reiterada ou não, o crime de tráfico de drogas.

Consta, ainda, que no dia 01 de abril de 2020, por volta de 12h55, na Rua Vinte, nº 9-A, Bairro Parque Rodrigo Barreto, nesta cidade e comarca de Arujá, os acusados guardavam e tinham em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 38,87g (trinta e oito gramas e oitenta e sete decigramas) de cocaína, acondicionados em 142 eppendorfs, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a exordial acusatória, os acusados, em data anterior a 01 de abril de 2020 e até tal data, associaram-se entre si com a finalidade de praticarem tráfico de drogas nesta cidade de Arujá, inclusive dividindo tarefas entre si. Nessas condições, guardavam, no interior da residência situada no endereço supra, 142 porções de cocaína, para fins de entrega a terceiros.

No dia 01 de abril de 2020, policiais militares receberam denúncia de que no local dos fatos havia um carro de marca Fiat/Palio, cor prata, com drogas em seu interior. No local os policiais avistaram o referido carro de placa DRC 3772 em

frente à residência de nº 9-A, sendo que, o veículo estava com o vidros abertos e a ignição ligada, porém, sem ocupante.

Ao se aproximarem do portão em frente ao qual o veículo estava parado, os policiais puderam avistar o acusado Delivan, que ao perceber a presença dos policiais correu para os fundos, diante da atitude suspeita, os policiais tentaram ingressar na residência sendo impedidos pelo acusado Anderson que forçou o portão e afirmou que ninguém entraria em sua residência.

Os policiais solicitaram apoio, e com a chegada da ajuda, conseguiram adentrar ao imóvel, onde em revista a parte externa localizou uma sacola branca no chão da propriedade, contendo em seu interior 142 eppendorfs de cocaína (fls. 145/148). Auto de prisão em flagrante (fls. 01). Boletim de ocorrência (fls. 08/12). Auto de exibição e apreensão (fls. 14/15). Laudo químico-toxicológico (fls. 17/19 e 379/381). Laudo de exame corporal (fls. 366/367 e 368/369). Folha de antecedentes (fls. 319/321 e 322).

Foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 71/75).

Foi concedida liberdade provisória ao réu Delivan (fls. 100/105), com cumprimento do alvará de soltura em 24/04/2020 (fls. 122).

Os réus foram notificados e apresentaram defesa preliminar (fls. 266/268 e 269/271).

Foi recebida a denúncia em 29/01/2021 (fls. 276/277).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e ao final interrogados os réus (fls. 339/340 e 393/397), sendo concedida liberdade provisória ao réu Anderson em audiência, com cumprimento do alvará de soltura em 10/09/2021 (fls. 388).

O Ministério apresentou alegações finais e postulou pela parcial procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia. Aduziu que quanto ao crime de associação do artigo 35 da Lei de Drogas, carece o feito de elementos probatórios suficientes a indicar que houvesse estabilidade e permanência na associação criminosa. Quanto ao crime de tráfico de drogas, pugnou pela condenação dos réus nos exatos termos da denúncia. Na dosimetria pleiteou a exasperação da pena-base em razão da quantidade e potencialidade das drogas e pelo fato de o réu Anderson ostentar maus antecedentes. Na segunda fase incide a agravante da reincidência para Anderson. Na terceira fase pleiteou a não aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, por se dedicarem os réus à atividade criminosa, sendo incompatível sua ação com a traficância eventual e particular. Pugnou pela aplicação do regime fechado (fls. 412/417).

A defesa dos réus Anderson e Delivan requereu a absolvição do réu por falta de provas, sustentando que nada de ilícito foi encontrado na posse dos acusados. Asseverou que os acusados residem com sua família no local. Pugnou pela aplicação do princípio do in dubio pro reo ao caso. Pleiteou que seja assegurado ao réu o direito de recorrer em liberdade (fls. 421/424 e 425/428).

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Os autos estão em ordem. Não há preliminar a ser apreciada ou nulidade a ser declarada. Logo, o feito está apto a ser julgado.

A pretensão punitiva estatal é improcedente.

A materialidade do delito de tráfico de drogas está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, laudo toxicológico, demais documentos e prova oral produzida.

A autoria, no entanto, é incerta.

Passo à análise da prova oral.

A testemunha Antonio Marcos, policial militar, disse que foi irradiado na rede de rádio um veículo Palio, cor prata, em atitude suspeita, que estava indo entregar uma quantidade de droga. Relatou que visualizaram o veículo em frente à residência e quando desembarcou da viatura o Delivan correu para o fundo da residência, o carro ficou aberto e ligado na via pública. Contou que ao tentar realizar a abordagem, o Anderson veio para cima da equipe, tiveram que esperar apoio para entrar na residência e localizaram a droga próxima a um córrego da residência. Informou que depois foi confirmado que o carro era do Delivan, ele entrou na residência e depois o localizaram lá dentro. Aduziu que na residência tinha o

Delivan, o Anderson e outras meninas, foi a maior briga na hora da abordagem. Disse não recordar se as meninas eram menores. Observou que não demorou mais do que cinco minutos para chegar o reforço. Comentou que com os réus não foi localizado nada no corpo. Falou que a sacola foi encontrada do lado da casa, onde tem uma criação de bicho e fica próximo ao córrego. Afirmou que os réus não deram explicação sobre a droga. Explanou que o Delivan correu com a sacola lá para o fundo e dispensou a sacola. Disse que visualizou o Delivan sair do carro e dispensar a droga. Comentou que Anderson e Delivan se conheciam. Noticiou que Anderson é totalmente agressivo, veio para cima, bateu o portão na cara do depoente. Salientou que o local é conhecido como ponto de tráfico, mas o rapaz não conhecia.

A testemunha Lilian, policial militar, disse que na data dos fatos o Copom irradiou ocorrência sobre um veículo Palio prata, que estaria pela Rua Vinte e Três, transportando entorpecentes, realizaram o patrulhamento, quando adentraram na Rua Vinte, localizaram o veículo estacionado em frente ao portão número nove. Aduziu que desceram e verificaram que o veículo estava ligado, com a porta fechada, mas com a chave na ignição. Disse que quando olharam o portão visualizaram o Delivan indo para o fundo do local, o Anderson veio até o portão, começou a xingar, proferir palavras de baixo calão, empurrou seu parceiro e trancou o portão. Externou que pediram apoio das demais viaturas pelo rádio, conseguiram adentrar o local, porém os familiares do Anderson ouviram a gritaria, começou a entrar um monte de gente no local, tumultuando e interrompendo a abordagem. Contou que em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, seu parceiro foi para o fundo do local, a depoente ficou na parte da frente. Falou que no fundo do local onde tem animais e um córrego, seu parceiro encontrou uma sacola com vários entorpecentes. Mencionou que ele resistiu à prisão, foi necessário o uso de algemas e conduziram as partes ao DP. Disse que segundo informado na ocasião a residência é do Anderson, e ele e Delivan são amigos, os demais são familiares porque lá eles trabalham com ferro velho e reciclagem. Falou que quando chegaram no local o Delivan estava indo para o fundo, provavelmente acabou de chegar, porque o carro estava ligado e ao ver o Anderson xingando ele foi para a residência. Esclareceu que o Delivan foi para o fundo, ele não correu e fugiu, porque ele não resistiu à abordagem. Noticiou que é recorrente esse tipo de ocorrência no bairro, inclusive seu parceiro é conhecido, tem apelidos e o pessoal já hostiliza ele. Disse acreditar que ao ver a confusão Delivan se afastou do local para não se envolver. Pontuou que tem a residência, o comércio ao lado, e no fundo tem um córrego, animais com galinha, e seu colega não encontrou a droga com o Delivan, mas sim perto desse córrego. Disse não recordar se seu colega disse que viu Delivan com a sacola, mas recorda dele ter falado que viu Delivan ir para o fundo. Explanou que Anderson foi hostil, xingou muito, e foi agressivo, visivelmente havia possibilidade de estar embriagado, ele estava bem alterado.

O réu Delivan disse que tem 33 anos, trabalha numa chácara, ganha mil e duzentos reais por mês, estudou até o primeiro ano do ensino médio, é solteiro e não tem filhos, nunca foi processado antes. Afirmou que a acusação não é verdadeira. Externou que chegou na casa do Anderson, ele abriu o portão, entrou na casa, lá estavam conversando sentados, quando bateram no portão. Falou que o Anderson saiu para ver o que estava acontecendo, o depoente continuou sentado dentro da casa. Acrescentou que ouviu um barulho e quando se deparou os policiais estavam na casa apontando a arma, perguntando se o carro que estava lá fora era seu, respondendo o depoente que era seu sim. Contou que saiu com os policiais, foi conduzido para fora do portão, eles estavam com o Anderson no chão, usando força contra ele, depois chegou a família dele. Observou que a policial revistou seu carro, falaram que estava tudo tranquilo porque não tinha nada no carro. Contou que os policiais começaram a agredir o Anderson, o depoente ficou de canto só vendo a abordagem. Aduziu que seu carro estava com a ignição ruim, não estava ligado, vendeu o carro e o pegou de volta, disse que se desliga ele não consegue tirar a chave. Disse que respondeu para a policial que trabalha num sítio e nunca teve passagem e ela disse que não ia acontecer nada, para ficar tranquilo. Falou que depois chamaram o Anderson e disseram para entrar no camburão. Destacou que depois entrou outra viatura, foram para o fundo da casa dele e falaram que acharam entorpecente,

perguntaram se era nosso, mas responderam que não. Falou que os levaram ao hospital e depois para a Delegacia. Comentou que pegaram a droga do fundo, os policiais a trouxeram. Externou que o policial mostrou a droga.

O réu Anderson disse que tem 40 anos, trabalhava como cuidador de cavalos, ganhava mil e quinhentos reais, estudou até a primeira série, é separado e tem um filho, já foi processado antes por roubo e foi condenado. Relatou que chegaram em sua casa e começaram a bater em seu portão, quando chegou no portão o policial se identificou como macumbeiro e mostrou uma tatuagem de caveira que ele tem na mão direita. Falou que ele entrou no portão, disse que já o conhecia e que tinha pego uns dias de cadeia. Externou que mandou o depoente deitar no chão e pisou em suas costas, a família do depoente chegou e começou a fazer "vuco", então o policial empurrou seu sobrinho de 14 anos no chão. Salientou que seu irmão disse que ia informar a Corregedoria e ele estava gravando o que aconteceu. Esclareceu que Delivan não estava perto, mas estava na casa. Informou que o policial o xingou e o depoente o xingou também, pois em vez de se identificar como policial se identificou como macumbeiro. Aduziu que depois de minutos abriu o portão, o policial chegou derrubando e empurrando, foi aí que sua família começou a tumultuar. Comentou que não é dessa forma que se chega na casa dos outros sem mandado nenhum. Falou que perguntado pelo policial respondeu que o dono do carro estava no fundo da casa. Disse que o policial voltou do fundo da casa com o Delivan, revirou o carro dele e não achou nada. Ressaltou que o policial os colocou dentro da viatura, o pessoal perguntou para o policial que se não achou nada no carro e na casa porque iam prender, o policial disse que ia levar para a Delegacia para fazer declaração. Afirmou não ter visto droga nenhuma em sua casa, se ele tivesse apresentado a droga o pessoal teria falado. Contou que já viu o policial perto da Rua Vinte e Três onde tem um ponto de droga, o depoente mexe com cabrito, cavalo e vende galinha, o policial sempre passava em frente. Afirmou que Delivan é um conhecido, não tinha muita amizade com ele, fez curso com o irmão dele. Contou que na casa estavam seus sobrinhos, seu irmão e a mulher dele, eles presenciaram o que ocorreu e foi até gravado. Pontuou que abriu o portão e eles entraram já derrubando no chão. Essa foi a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

De início, impõe-se absolver os réus no tocante ao crime de associação para o tráfico, conforme requereu o próprio Órgão Ministerial em sede de alegações finais. Isto porque, não restou devidamente demonstrado no caso em tela a prática do delito de associação para o tráfico, eis que os elementos probatórios são insuficientes à certeza de sua ocorrência.

Como é cediço, o crime do art. 35 da lei 11.343/2006 é uma espécie de quadrilha ou bando específico do tráfico ilícito de entorpecentes, exigindo para a sua configuração a comprovação de sua permanência. Afirmar Guilherme de Souza Nucci (2009, p.365):

“Demanda-se prova de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa.” E mais: “exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no animo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática de crime de tráfico.”

No caso em testilha, não tendo sido comprovado o caráter de estabilidade e permanência da associação, não há como se imputar aos acusados a prática do crime em questão, não tendo, desta feita, se desincumbido o Ministério Público do ônus probandi que lhe é imposto.

No mesmo sentido, manifesta-se a jurisprudência, inclusive a do Superior Tribunal de Justiça:

Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343.2006”. (HC 349837/SP, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, v.u., j. 03.05.2016. No mesmo sentido REsp 1501842/PR, 6ª Turma, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, v.u., j. 05.04.2016).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DENÚNCIAS ANÔNIMAS QUE APONTAVAM NOMINALMENTE AS PESSOAS DOS RÉUS COMO TRAFICANTES - APREENSÃO DA DROGA EM LOCAL PRÓXIMO - ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - TESES DEFENSIVAS NÃO COMPROVADAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - RECURSO MINISTERIAL - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - AUSÊNCIA DE PROVA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO - MANUTENÇÃO - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 - POSSIBILIDADE. - Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se de qualquer outra testemunha fossem, eis que prestam compromisso e estão sujeitos às penalidades legais pelo falso, mostrando-se hábeis, portanto, a confirmar os fatos expostos no flagrante e comprovar a autoria delituosa. - Tendo os policiais recebido denúncia anônima apontando as pessoas dos réus como traficantes, e sendo eles abordados em lugar conhecido como ponto de venda de drogas, apreendida em local próximo elevada quantidade de entorpecentes, deve ser mantida a condenação. - Para caracterização do crime do art. 35, da Lei nº 11.343/06, deve ser comprovada a estabilidade e permanência do vínculo associativo, não demonstradas no presente caso, mantendo-se a absolvição declarada na sentença. (TJ-MG - APR: 10079073229183001 MG, Relator: Delmival de Almeida Campos, Data de Julgamento: 15/05/2013, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/05/2013, undefined)

Como mencionado alhures, mesmo que entendêssemos estarmos diante de alguns indícios de associação, isso não deve bastar para caracterizar a culpabilidade dos réus pelo delito em questão, especialmente quando toda a investigação não veio acompanhada de uma apuração mais rigorosa destas circunstâncias.

No caso, pode-se até cogitar de probabilidade do crime de associação, mas o fato é que, "no processo criminal, máxime para condenar, tudo deve ser claro como a luz, certo como a evidência, positivo como qualquer expressão algébrica. Condenação exige certeza absoluta, fundada em dados indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade desta ou daquele. E não pode, portanto, ser a certeza subjetiva, formada na consciência do julgador, sob pena de transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio." (RT 619/267).

Outrossim, para configuração do delito de associação não se exige que os componentes da associação se conheçam e que haja nítida divisão de funções. Basta, apenas, que a associação vise à prática de um número incerto de crime, por tempo indeterminado (elemento subjetivo do tipo). No caso dos autos, todavia, a presença de vínculo estável e psicológico entre os agentes não restou evidenciada pelas provas produzidas.

Registre-se que não houve investigação prévia sobre a atuação dos acusados ou mesmo posterior que pudesse confirmar o vínculo associativo descrito na exordial acusatória. Ademais, os próprios réus, à sua maneira, negaram a associação, dizendo que mal se conheciam.

Ainda, não foram encontrados com os acusados anotações, balança ou outros insumos que pudessem revelar ou confirmar uma ligação estável e permanente entre eles para prática reiterada de crimes, nem mesmo de tráfico.

Quanto ao delito de tráfico, como já referido alhures, a conclusão não é outra, inexistindo elementos aptos a impor a condenação aos réus.

Os laudos periciais comprovam a natureza da droga encontrada, indicando que o material apreendido consistia de fato em cocaína, droga com maior poder vulnerante. Entretanto, o depoimento dos policiais, além de não ser inteiramente uníssono e coeso, resta enfraquecido pela versão dos réus.

Veja-se que a dinâmica dos fatos, por si só, dificulta a identificação do suposto portador da droga apreendida, gerando razoável dúvida acerca da autoria, como será melhor explanado adiante.

Em resumo, segundo relatado pelos policiais, teriam eles recebido denúncia via Copom sobre um veículo que estaria distribuindo drogas, sendo pertencente o automóvel a Delivan, que estava parado em frente à residência de Anderson. No

local, após dissensões e certo tumulto os policiais teriam apreendido os réus, vindo a localizar, nos fundos da residência, a sacola contendo os 142 ependorffs de cocaína.

Ocorre que há conflitos entre as versões dos policiais acerca de detalhes atinentes aos fatos.

A testemunha Antonio Marcos disse expressamente que viu Delivan saindo do carro, correndo com a sacola branca contendo drogas para dentro do terreno, onde a teria dispensado. Contudo, a testemunha Lilian disse que visualizaram o Delivan indo para o fundo do local, esclarecendo que ele não correu e fugiu, porque não resistiu à abordagem, dizendo acreditar que Delivan se afastou ao ver a confusão, pontuando que seu colega não encontrou a droga com Delivan, mas sim perto do córrego, arrematando, por fim, que não recorda se seu colega disse que viu Delivan com a sacola, mas recorda dele ter falado que viu Delivan ir para o fundo.

De outro lado, ambos os policiais afirmaram que nada foi encontrado com os réus em revista pessoal, nem tampouco no veículo de Delivan ou dentro, propriamente, da residência de Anderson.

Além disto, segundo se observa, a droga foi localizada dentro do terreno, próximo a um córrego e onde eram criados animais, sendo certo ainda que havia outras pessoas dentro da residência onde ocorreu a abordagem, que seriam parentes do réu Anderson. Diante disto, não é possível ter plena certeza de que a droga pertenceria exclusivamente a um ou outro réu, nem mesmo a ambos, já que não foi localizada na posse deles, nem mesmo no veículo de Delivan ou dentro da casa de Anderson.

Do mesmo modo, não se pode descartar que a droga poderia pertencer a outra pessoa, um dos familiares do réu Anderson que estavam no local, ou mesmo a terceiro desconhecido que poderia ter lançado a sacola ao solo, próximo ao córrego, em outra oportunidade, vindo a ser descoberta, por acaso, na ocasião da abordagem.

Os réus, por sua vez, negaram a autoria do delito, dizendo Delivan que apenas foi visitar Anderson, tendo aquele dito que nada havia consigo, nem em seu veículo, bem como que não tinha conhecimento da droga. Já Anderson apenas afirmou que estava em sua casa quando foi abordado pela polícia, pedindo para abrir o portão, tendo relatado que não avistou droga no local.

Não foram encontrados no imóvel do acusado Anderson embalagens para divisão e venda da droga, nem anotações de tráfico, balanças, insumos ou quaisquer outros instrumentos que estão usualmente atrelados ao delito. Ademais, não foram apreendidos os celulares dos acusados, não ficando evidenciada qualquer comunicação entre eles que indicassem tráfico de drogas ou tratativas relativas ao tráfico.

Convém anotar ainda, por oportuno, que a prova oral confirma que outras viaturas participaram das abordagens e diligências policiais, e estes não foram arrolados. Do mesmo modo, sequer foram trazidas a depor as demais pessoas que se encontravam no local e presenciaram a abordagem.

O simples fato de terem sido abordados no local não seria suficiente para apontá-los como proprietários dos entorpecentes. Mesmo porque, os próprios policiais que realizaram a abordagem disseram que não foram encontradas drogas, dinheiro ou aparelho celular em poder dos acusados.

Em suma, pelas provas produzidas, não ficou comprovado o encontro dos entorpecentes em poder dos acusados. Os policiais apenas confirmaram a versão trazida na denúncia e repetiram o que haviam declarado em sede policial, não sendo trazidas outras testemunhas para depor, nem mesmo os demais indivíduos presentes.

Assim, apesar da apreensão da sacola com entorpecentes no terreno onde os policiais apreenderam os réus, as circunstâncias do caso não permitem concluir de forma segura que tal sacola efetivamente pertencia aos acusados. Desse modo, os depoimentos prestados nos autos trazem dúvida sobre como de fato ocorreu a apreensão da droga indicada em auto de exibição e apreensão.

Observa-se ainda que os policiais afirmaram ter recebido denúncia anônima de que um indivíduo num veículo prata estaria realizando a distribuição da droga, porém não acostaram qualquer cópia da gravação ou áudio dessa denúncia.

Vale observar que a justificativa apresentada pelos policiais para ingressar na casa de Anderson seria a referida denúncia, que sequer foi apresentada, bem como a suposta visualização da sacola de entorpecente que estava com Delivan pelo policial

Antonio Marcos, o que tampouco se confirmou pelo relato da policial Lilian. E conforme entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC 598.051, a autorização do morador para ingresso em domicílio, quando não houver mandado judicial, deve ser registrada pelos policiais em áudio e vídeo, para não haver dúvida acerca desse consentimento nem da legalidade da ação. Além disso, a entrada deve ter fortes razões que a justifiquem, não bastando a referência à desconfiança policial ou mera atitude suspeita. Ocorre que no caso particular dos autos tal registro não foi feito, pendendo dúvida sobre a autorização de entrada no imóvel, o que justificaria, por si só, a absolvição em razão da nulidade da prova apresentada. Ainda, não houve visualização de qualquer ato de traficância e os relatos dos policiais não trouxeram qualquer elemento concreto que pudesse apontar, com a certeza necessária, que os acusados realizavam o comércio espúrio de drogas. Outrossim, não houve exame datiloscópico na sacola apreendida, não se comprovando que haveria digitais dos acusados em tal objeto. Diante de tal quadro, restam dúvidas acerca da propriedade das drogas localizadas, que poderiam ou não pertencer aos acusados. Ademais, as declarações dos réus não se mostram de todo inverossímeis, tendo apresentado uma versão razoavelmente consistente, indicando que não participavam da atividade ilícita. Sua versão, neste contexto, não merece ser necessariamente descartada. Importa, observar, neste ponto, que milita em favor do réu Delivan o fato de não ostentar outras passagens criminais em seu desfavor, tratando-se de indivíduo primário (fls. 322). Como se pode observar, os elementos probatórios trazidos pelo órgão acusador limitam-se, efetivamente, à oitiva dos policiais responsáveis pela prisão dos acusados, o que, no entender desta magistrada, não constitui um conjunto probatório suficiente à prolação de uma condenação nos termos postulados. Isso porque, os depoimentos dos policiais se mostraram pouco esclarecedores e cuidaram apenas de repetir uma versão dada em sede policial, sem trazer qualquer outra evidência a robustecer a tese acusatória. De outro lado, o depoimento dos réus, mostrou-se contundente, e, conquanto não baste a afastar de maneira cabal a autoria do delito ou mesmo a sua materialidade, ante a existência de depoimentos de policiais em sentido contrário, prestam-se, inequivocamente a derrubar qualquer certeza de culpabilidade necessária à prolação de um decreto condenatório. Registre-se que ao réu não incumbe a prova de sua inocência, de modo que o fato de os acusados não terem trazido uma testemunha que corroborasse a sua versão não afasta, de forma alguma, o ônus do Ministério Público de comprovar, de maneira robusta, a sua culpabilidade. É importante salientar que em delitos de tráfico de drogas, cometidos, normalmente, na clandestinidade, a prova, em regra, se refere a depoimentos dos policiais, que de modo geral, são suficientes a demonstrar a culpabilidade de um réu, desde que em consonância com as demais provas carreadas aos autos, o que, todavia, não se amolda ao caso em questão. Não se trata aqui, de forma alguma, de desqualificar todo e qualquer testemunho prestado por policiais, mas de estar atento a possíveis falhas perpetradas por estes no exercício de sua função, que podem até incluir imputações precipitadas. Nessa mesma toada, manifesta-se a jurisprudência:

EMENTA: TRÁFICO DE DROGAS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - NECESSIDADE - PALAVRA ISOLADA DOS POLICIAIS. A versão policial isolada sobre a prática do crime não forma conjunto probatório suficiente para sustentar a convicção sobre a destinação da droga apreendida e, portanto, não autoriza a condenação pelo crime de tráfico de drogas. (TJMG - Apelação Criminal 1.0699.16.010381-7/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/11/2018, publicação da súmula em 03/12/2018).

Neste sentido também é o ensinamento de Gustavo Badaró:

Quanto ao testemunho dos policiais, há correntes radicais, que, pelo seu próprio extremismo, devem ser descartadas. Uma dessas correntes entende que o fato de a testemunha ser policial, por si só, não a torna impedida de depor, não havendo qualquer disposição legal neste sentido. Ao contrário, o policial não se enquadra nas hipóteses do artigo 207 do CPP, devendo ser dado ao seu depoimento o mesmo valor de qualquer outra testemunha. De outro lado, há corrente oposta, no sentido de que os policiais, pela simples condição funcional, seriam suspeitos. Deve prevalecer uma posição intermediária: se os policiais não podem ser considerados suspeitos, pelos simples fato de serem policiais, por outro lado, é inegável o seu interesse na demonstração da legalidade de sua atuação nos atos investigatórios praticados, pelo que seus depoimentos têm valor relativo, devendo ser cotejados com outros elementos de provas existentes nos autos, em especial o testemunho de pessoas estranhas aos quadros da polícia. Não se pode esquecer que as testemunhas são, por definição, terceiros imparciais, sem qualquer interesse no processo, o que não é exatamente o caso dos policiais em relação aos crimes por ele investigados. Por tais motivos, não se deve admitir que seja proferida uma sentença condenatória com base exclusiva no depoimento de policiais, ainda que estes se demonstrem harmônicos entre si (BADARÓ, Gustavo Henrique; Processo Penal. São paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, página 477/478).

Em sentido semelhante ao aqui exposto, esclarece, de forma muito didática, Aury Lopes Jr:

Da mesma forma, não há que se falar em restrição ao depoimento dos policiais. Eles podem depor sobre os fatos que presenciaram e ou dos quais têm conhecimento, sem qualquer impedimento. Obviamente, deverá o juiz ter muita cautela na valoração desses depoimentos, na medida em que os policiais estão naturalmente contaminados pela atuação que tiveram na repressão e apuração do fato. Além dos prejulgamentos e da imensa carga de fatores psicológicos associados à atividade desenvolvida, é evidente que o envolvimento do policial com a investigação (e prisões) gera a necessidade de justificar e legitimar os atos (e eventuais abusos) praticados. Assim, não há uma restrição ou proibição de que o policial seja ouvido como testemunha, senão que deverá o juiz ter muita cautela no momento de valorar esse depoimento. A restrição não é em relação à possibilidade de depor, mas sim ao momento de (des)valorar esse depoimento.

Contudo, é recorrente o Ministério Público arrolar como testemunhas apenas os policiais que participaram da operação e da elaboração do inquérito. Busca, com isso, judicializar a palavra dos policiais para driblar a vedação de condenação "exclusivamente" (art. 155 do CPP) com base nos elementos informativos colhidos na investigação. Na continuação, deparamo-nos com sentenças condenatórias em que são utilizados os elementos do inquérito e o depoimento dos policiais em juízo. No fundo, é um golpe de cena, um engodo, pois a condenação se deu, exclusivamente, com base nos atos da fase pré-processual e no depoimento contaminado de seus agentes, natural e profissionalmente comprometidos com o resultado por eles apontado, violando o disposto no art. 155 do CPP. Portanto, se não há impedimento para que os policiais deponham, é elementar que não se pode condenar só com base nos seus atos de investigação e na justificação que fazem em audiência." (2019, p.462)

Aliás, na linha do que está sendo exposto, se a ideia fosse tomar como absoluta e incontestável toda e qualquer declaração prestada por testemunhas policiais no bojo do processo penal, despicienda seria a instrução probatória e até mesmo a valoração da prova colhida pelo Juiz de Direito.

Outrossim, como este juízo sempre vem asseverando, não é demais exigir do órgão acusador, a quem se impõe o ônus probandi, a reunião de outros elementos probatórios que não se limitem à mera repetição das declarações dos policiais que efetivaram a prisão do acusado, até porque, como consignado alhures, é natural que estes objetivem legitimar sua própria atuação. Por um outro viés, estes mesmos policiais já dispõem, nos dias atuais, de outros instrumentos e mecanismos aptos a



robustecer os motivos ensejadores da prisão e da persecução penal, conferindo às suas declarações um caráter de veracidade quase irrefutável, como já se pôde constatar em outras oportunidades, em que os policiais se valeram, inclusive, de gravações audiovisuais para registrar as abordagens, diligências e operações. Pontua-se também, mais uma vez, que não foi trazida nenhuma testemunha distinta dos policiais que pudesse corroborar os seus relatos, o que certamente robusteceria a prova acusatória. Neste sentido são as palavras do eminente jurista Guilherme de Souza Nucci:

Parece-nos cauteloso que o magistrado, visualizando, em processos de apuração de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, um rol de testemunhas de acusação formado somente por policiais, indague os mesmos a razão pela qual não se obteve nenhuma pessoa, como testemunha, estranha aos quadros da polícia. Essa verificação é essência, pois uma apreensão de drogas feita à vista de inúmeras pessoas, em local público, por exemplo, pode perfeitamente contar com o testemunho de pessoas que não sejam policiais. (NUCCI, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 2009, p. 353).

Voltando ao caso em questão, cumpre indagar, ante aquilo que foi exposto, se o quanto relatado pelos policiais pode, na hipótese em tela, ser considerada uma prova robusta e coerente para fins de fundamentalmente arrimar uma condenação por tráfico de drogas. No entendimento deste Juízo, não é. Forçoso, in casu, verificar que, tendo negado os réus a propriedade ou porte da droga, ressaltando que a droga lhe teria sido atribuída pela polícia como sendo sua, e não havendo, além das declarações dos policiais, qualquer outra prova que confirme a prática de tráfico de entorpecente, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo em favor dos acusados, de modo a permitir que este seja absolvido da imputação que lhe fora direcionada. Com isso, repita-se, não se conclui pela necessária ocorrência de um flagrante forjado, mas sim, pressupõe-se que, havendo dúvida do que ocorreu na data dos fatos, deve ser aplicada a máxima mencionada, já que a dúvida milita em favor do acusado.

Em sentido semelhante, manifesta-se a jurisprudência:

TÓXICO - Crime de tráfico e associação para o tráfico - Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à posse ou propriedade da droga apreendida - Mercancia não comprovada - Indícios insuficientes para formar convicção nesse sentido - Réu preso em companhia de menor reconhecido e indicado como traficante - Ausência de atos seguros e concretos vinculando suas ações - Depoimento de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Dúvida remanescente que autoriza o decreto absolutório - Recurso provido - (TJSP, APELAÇÃO N°: 990.09.047397-5 - COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA APTÉ WELLINGTON DA SILVA SANTOS APDO : Ministério Público).

Como se vê, os elementos amealhados no curso da instrução penal não permitem concluir com um mínimo de segurança que os acusados traziam consigo a droga ou que praticavam o crime inserto no art. 33, caput da lei 11.343/06, impondo-se com isso, a sua absolvição.

Assim, a despeito da probabilidade da ocorrência do tráfico de drogas e mesmo que se considere pouco crível a versão apresentada pelos réus, o conjunto probatório produzido não se mostra firme o bastante para lastrear uma condenação por tráfico de drogas.

Destarte, nesta fase processual, encerrada a instrução, se alguma dúvida existe deverá ser interpretada em favor dos réus, conforme recomenda a boa técnica processual penal.

Como é cediço, em casos de dubiedade, de provas colidentes ou de insuficiência probatória, o respeito à máxima da presunção de inocência impõe a absolvição da acusada como medida de justiça. Sobre a presunção de inocência, manifesta-se Aury

Lopes Jr. (Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional, vol I. Rio de Janeiro:Lumen Juris, 2008, p.178/19):

...é princípio fundamental de civilidade, fruto de uma opção garantista a favor da tutela da imunidade dos inocentes, ainda que para isso tenha-se que pagar o preço da impunidade de algum culpável. Isso porque, ao corpo social, lhe basta que os culpados sejam geralmente punidos, pois o maior interesse é que todos os inocentes, sem exceção, estejam protegidos.

Se é verdade que os cidadãos estão ameaçados pelos delitos, também o estão pelas penas arbitrárias, fazendo com que a presunção de inocência não seja apenas uma garantia de liberdade e de verdade, senão também uma garantia de segurança (ou de defesa social), enquanto segurança oferecida pelo Estado de Direito e que se expressa na confiança dos cidadãos na Justiça. É uma justiça que se oferece ao arbítrio punitivo.

Assim, mesmo que implique a absolvição de um culpado, a presunção da inocência deve ser integralmente aplicada quando nos autos não subsiste a certeza indispensável à prolação de um decreto condenatório, sendo certo que muito mais grave e deletério a um Estado Democrático de Direito do que soltar um culpado é impor a um inocente uma condenação penal e submetê-lo aos rigores e amarguras de uma pena privativa de liberdade.

A responsabilidade penal deve estar estreme de dúvidas e não pode ser atribuída a um sujeito de maneira precipitada. É preciso que as provas carreadas aos autos demonstrem de forma inequívoca que o acusado foi do crime, de maneira que seja possível lhe imputar a prática do delito, o que não ocorreu no caso em questão. Fato é que, sem a taxatividade própria do direito penal, impossível exarar decreto condenatório, até mesmo porque:

“O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal proferir condenação” (Ac. un. da 5a. Câ., de 19-7-77, na Ap. n. 162.055, de Jaú, rel. GOULART SOBRINHO, ref. por Azevedo Franceschini, in Jurisprudência Penal e Processual Penal, vol. 8, pág. 313

Isto posto e por tudo mais que dos autos costa, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida e ABSOLVO os réus DELIVAN SANTANA SANTOS e ANDERSON DE OLIVEIRA MOTA, qualificados nos autos, das imputações que lhe foram dirigidas, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Expeça-se certidão de honorários ao patrono nomeado pela OAB/DPE.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Aruja, 30 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA